

1504376-81.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato

da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504376-81.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504376-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2050510/2022 - DEIC - 2ª

Del. Falsas Domésticas e Roubo de Jóias - DISCCPA, 14/2022 - DEIC - 2ª Del. Falsas

Domésticas e Roubo de Jóias - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAYQUE FERREIRA DE MELLO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 433/22

VISTOS.

CAYQUE FERREIRA DE MELLO e MAYARA FERREIRA AIDAR, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao disposto no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque consta, que no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00m, na Rua Ushikichi Kamiya, à altura do n.º 598, Tremembé, nesta cidade e Comarca, em associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, traziam consigo e transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 (três) folhas de papel contendo ADBBUTINACA, substância vulgarmente conhecida como "K4", com peso líquido de 19,8g (dezenove gramas e oito decigramas), as quais, ante as circunstâncias da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida à fl. 118.

Foram apresentadas defesas preliminares.

Durante a instrução processual, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, cinco testemunhas de acusação e os réus foram interrogados.

Convertidos os debates em memoriais, fls. 328/338, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime. Ademais, apontou como incabível a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

A Defesa de CAYQUE, por seu turno, também em memoriais, às fls. 343/352, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, afastamento da reincidência, reconhecimento da causa especial de diminuição, pena no mínimo, substituição da pena por restritiva de direitos, regime mais brando e direito de recurso em liberdade.

A Defesa de MAYARA, às fls. 357/368, também requereu a absolvição da ré pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da causa especial de diminuição, pena no mínimo, substituição da pena por restritiva de direitos, regime mais brando e direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19, dando conta das folhas de papel contendo K4, localizados e apreendidos em poder dos réus.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 153/155 atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para ADB-BUTINACA.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos das Doutas Defesas não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra os réus derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações dos próprios increpados, que nada de exculpatório trouxeram aos autos.

Na fase inquisitiva, ambos confessaram que receberiam ou receberam dinheiro para entregar e receber o envelope, fls. 09/12.

Em juízo, o réu CAYQUE declarou que eu gostaria que minha esposa não soubesse, porque eu tinha um envolvimento com Mayara, e a gente tinha relação e usava drogas juntos e se encontrava constantemente. Eu deixei o envelope com Mayara. Eu pedi para o motoboy entregar o envelope para Mayara porque não queria que minha esposa soubesse. A gente ia usar a droga juntos, a gente ia dividir. A droga é usada fumando, junto com tabaco. Já tenho uma condenação por roubo. Tenho 27 anos de idade. Não conhecia os policiais. Brenda é a minha namorada, não do meu irmão. Ela não é minha esposa, é minha namorada. Acredito que meu irmão não queria me prejudicar, por isso ele disse que parou no posto por vontade dele. Não conhecia Bruno, ele estava lá, mexendo numas caixas. Cada folha dessa droga custa aproximadamente 600 reais. Eu comprei uma, Mayara comprou a outra e a outra a gente ia dividir.

Já a ré MAYARA declarou, sob o crivo do contraditório, que eu e o Cayque a gente já se conhecia, já saímos e fizemos uso de drogas juntos. Eu fui na cracolândia e busquei essa droga para dividir com ele. O envelope estava comigo e eu e o Cayque íamos dividir. Na delegacia fui instruída a dizer que o envelope estava com ele porque senão eu seria presa. Nunca fui processada anteriormente. Eu nem vi nenhum motoboy. Eu cheguei no ponto de táxi, desci do táxi e estava aguardando Cayque para a gente fazer a divisão. Eu que estava com o envelope.

Ocorre, porém, que, enquanto as confissões extrajudiciais dos acusados vieram embasadas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, suas negativas judiciais restaram solteiras e em absoluto não convenceram. A versão judicial apresentada pelos réus de que estavam eles, na realidade, envolvidos em um relacionamento amoroso e que as drogas seriam para seus usos em conjunto não é crível diante das evidências do caso em concreto.

Inicialmente há que se levar em conta as contradições existentes entre as

declarações deles, feitas na delegacia de policia e em Juízo.

Veja que os acusados afirmam que a droga seria destinada a seu uso conjunto, alegando serem eles um casal. Porém, veja que o próprio acusado e demais testemunhas confirmam que os fatos narrados na denúncia transcorreram estando a companheira do réu CAYQUE dentro do veículo que esse utilizava.

Ora, não se pode crer que os réus, caso de fato quisessem ocultar seus envolvimento românticos, combinassem uma entrega de entorpecentes em local público, na presença do irmão e da namorada de Cayque, de forma completamente desnecessária, haja vista que, fossem mesmo usar as drogas juntos, não haveria necessidade de se encontrarem previamente para a entrega da droga, o que poderia muito bem ser feito quando já estivessem juntos.

Nesse diapasão, não se pode crer que os acusados tivessem se encontrado em um posto de gasolina, com a droga sendo entregue por intermédio de terceiro alheio, dentro de um envelope e sem manterem eles dois quaisquer contato pessoal, quando fossem do nada acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso, e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

O montante e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas em poder dos réus não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que absolutamente incompatíveis com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, as atitudes suspeitas dos réus somada ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância. Até porque o tipo de droga em questão não é daqueles que se adquire de forma fácil, em plena cracolândia, como pretendem fazer crer os acusados.

O motoqueiro, Bruno da Rocha, em Juízo relatou que eu estava no posto, procurando um endereço, quando Cayque me pediu, de dentro do carro, para entregar o envelope para Mayara. A moça pegou o envelope, quando a polícia chegou. Mas eu não sabia de nada. Somente na delegacia que eles falaram que no envelope tinha drogas. Mayara estava no posto, pegou o envelope e entrou em outro carro, que ela estava.

Referida testemunha confirma a dinâmica dos fatos, no sentido de que realmente foi acionado por Cayque para que entregasse o envelope para Mayara.

Já o irmão do réu, Caio Henrique Ferreira de Mello, ouvido apenas como informante, declarou que eu trabalhava de manhã, quando meu irmão me pediu uma corrida até uma óptica. Eu parei em um posto de gasolina para abastecer, por conta própria, não foi Cayque que pediu para eu parar lá. Nisso, os policiais chegaram e nos prenderam.

Mayara estava lá. Meu irmão ficou o tempo todo dentro do carro, não vi se ele entregou algum envelope para Mayara, nem ela pegando nada, nem o motoqueiro. Eu vi o motoqueiro lá. Conhecia a ré Mayara de vista, da balada.

Não obstante, o depoimento da testemunha, ao contrário do que ocorre com os depoimentos dos policiais, não pode ser considerado imparcial. A uma porque afirma que nada sabia a respeito das drogas apreendidas nem, tampouco, sobre o suposto envolvimento amoroso entre os acusados. E depois porque irmão e próximo do réu, outra não poderia ser a conduta dele senão tentar, de todas as formas, inocentá-lo de tão grave acusação. Ademais, muitas vezes, mesmo tratando-se de pessoas próximas e ligadas aos agentes, não têm conhecimento acerca da traficância que praticam.

E assim é o entendimento porque, em sentido contrário ao relatado, temos os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão dos réus, Rodrigo Souza Neves e Adriano Sanches Martins, os quais, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme e segura que na data dos fatos, nós estávamos em diligências pela área e recebemos uma informação de campo, de que no local haveria uma entrega de drogas. Permanecemos em campana, quando vimos um veículo Voyage encostando no posto. O réu Cayque ocupava o carro, no banco de trás, e sinalizou para uma moto, que era conduzida por Bruno. Ele entregou o envelope para ele e fez um sinal para que fosse entregue para Mayara. Nós optamos pela abordagem, quando verificamos que no envelope entregue para Mayara continha as drogas K4. Cayque confirmou que efetuou a entrega para Mayara, a qual confirmou que receberia esse envelope, mas não sabia que era droga. Os demais ocupantes do veículo e o motoboy não tinham ciência das drogas. Tanto Mayara como Cayque afirmaram que Mayara não sabia que

tinha droga no envelope, que elas apenas foi contratada via WhatsApp para receber o envelope. Ela disse que receberia 200 reais para receber o envelope. Quem entregou o envelope para o motoboy foi o réu Cayque, de dentro do carro. Não foi apreendido nenhum valor em dinheiro. No momento da abordagem, a polícia militar chegou e nos apoiou na diligência. Reconheceram os réus e não os conheciam anteriormente. Os policiais civis narraram com segurança e precisão como se deram as prisões dos acusados, relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local em razão de diligências investigativas de entrega de drogas no local, a abordagem dos réus, o encontro das folhas de K4, suas confissões informais, até final detenção e prisão. A fala dos policiais coloca uma pá de cal sobre a versão tanto dos réus, como de suas defesas no sentido de que eram apenas usuários. Tanto é assim que ambos os acusados confessaram informalmente a traficância, situação que demonstra que seriam eles os vendedores e não meros usuários.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento".

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Para tanto, a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia pudesse vir a inocentar os acusados da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheram os réus um dos núcleos do tipo denunciado, sendo, pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não terem os agentes sido surpreendidos no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Em arremate, o fato dos réus serem também usuários em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental pois, com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários. Destarte, não se evidenciou qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar os réus

das penas.

Apenas um reparo merece a peça acusatória. O crime previsto no artigo 35 da Lei de Tóxicos não restou bem demonstrado nos autos. Ocorre que não se comprovou de forma inexorável que os acusados estivessem no local também vendendo drogas e que assim agiam de maneira estável, juntos. Veja que é breve o momento em que os policiais em campanha avistaram os dois réus, sendo apenas a entrega de um único envelope naquele momento o que se analisa neste presente processo. Não se conseguiu provar claramente que os réus atuavam de forma contínua, com tarefas estabelecidas, necessária ao reconhecimento da associação.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. A ré MAYARA é primária e não ostenta antecedentes criminais. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu CAYQUE é reincidente num roubo, conforme certidão de fls. 36/37, assim, aumento sua pena em mais 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação à ré MAYARA, na hipótese dos autos, forçoso se faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque a acusada primária, sem quaisquer antecedentes, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a quantidade de drogas, reduzo a pena base em 1/3, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em relação ao réu CAYQUE, não há que se falar em aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o condenado é reincidente, circunstância esta suficiente a afastar os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e aplicação da redução em apreço, nada havendo, portanto, que demonstre que não faz do crime um meio de vida.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida – 13 (treze) pedras de crack – justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3” (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar MAYARA FERREIRA AIDAR, como incurso nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa e CAYQUE FERREIRA DE MELLO, como incurso nas penas do artigo 33, da Lei nº11.343/06 a cumprir, em regime inicialmente fechado, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Julgo ainda improcedente a presente ação penal, para absolve-los das penas do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

O condenado CAYQUE iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado pois, além da reincidência, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8072/90 prevê, expressamente, que crimes dessa natureza terão suas penas cumpridas inicialmente em regime fechado. Além do mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, elencado pela Constituição Federal como inafiançável, sendo vedada a liberdade provisória, antes da condenação definitiva, quando prevalece a presunção de inocência, muita mais descabida é a concessão de qualquer regime diverso, com possibilidade de liberdade cautelar àquele que vem a ser condenado, mesmo que em primeiro grau. Não é possível,

tampouco, a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal. Qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade e em regime fechado, mostrar-se-ia por demasiado tênue, como forma de repressão e retribuição.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, "caput", da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Em arremate, o condenado respondeu a todo o processo preso e assim deve permanecer, pois foi nesta data condenado a crime de extrema gravidade, dos quais não se admite liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06. A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em especial, da prática de crimes como deste jaez, cujos agentes não se privam em aliciar jovens em nossas comunidades, causando transtornos irreparáveis em todos os cidadãos de bem. Assim sendo, presentes os requisitos legais, não concedo ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE -

adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvemento dos demais recursos."

Além disso, não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomende-se o réu CAYQUE no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Em relação à ré MAYARA, na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que a ré é primária, sem qualquer mácula em sua vida, foi solta no curso do processo e comprovou que se encontra trabalhando, sendo que fazê-la retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista, ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6x4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.
Custas na forma da lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA